جامعة راف العالمية.

مركز الدراسات العليا في نيروب كينيا.

تخصص– الشريعة

شعبة–أصول الفقه.

عنوان: البحث:تصرّفات القاصر بين الحكم التكليفي والوضعي.

(الصبي والمجنون والنائم نموذجا دراسة أصولية فقهية)

إعداد: مختار بشير جيد(المظهري)


بسم الله الرحمن الرحيم

هيكل البحث:وفيه مقدمة ومبحثان وثمانية مطالب:

المبحث الأول:تعريفات أولية لموضوع البحث:وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول:مفهوم القاصر لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني:تعريف الحكم التكليف

المطلب الثالث:تعريف الأحكام الوضعية

المطلب الرابع:الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي.

المطلب الخامس:أقسام الأحكام الفقهية باعتبار التكليف والوضع.

المبحث الثاني:تصرّفات القاصر وأحكامها في الفقه الإسلامي وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول:تصرّفات الصبي المميز وأحكامه في الشريعة الإسلامية

المطلب الثاني:تصرفات المجنون وأحكامه في الفقه إسلامي.

المطلب الثالث:تصرّفات النائم وأحكامها في الفقه الإسلامي

المقدمة:

الحمد الله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين فإن العقل مناط التكلبيف وبه يميز الإنسان عن غيره من الحيوانات،وهو أهم ميزة اختصّ الله به بني آدم وبها استحقّ الاسطفاء والاختيار،وسببها صار خليفة الله في أرضه، وبأهمية هذا العنوان حاولت جمع المعلومات المتعلقة في هذا الموضوع بطلب،من أستاذنا وشيخنا حفظه الله الدكتور محمد حسن أستاذ الفقه المقارن في جامعة راف.

المطلب الأول:مفهوم القاصر لغة واصطلاحا.

القاصر اسم فاعل من قصُر بالضمّ وقصَرَ بالفتح.

ويأتي الفعل المزيد من هذه المادة على (الإقصار).

وأبزر معاني لكلمة (قصر) معنيين.

الأول:عكس الطول قال في (اللسان): والقصر في كل شيء: خلاف الطول.

والثاني:العجز عن الإدراك والوصول إلى الشيء قال في(اللسان): وقصَرتُ عن الشيء قصورا: عجزت عنه ولم أبلغه([1]).

أما القاصر اصطلاحا:

فقد استخدم فقهاء الشريعة والقانون في العصر الحديث هذه الكلمة وأكثر استعمالاتهم تدور على الصبي مميزا كان أو غير مميز، يتيما كان أم لا،كما أنهم يستعملون مصطلح القاصر للدلالة على المجنون وكل من فقدالأهلية.

قال الدكتور وهبة الزحيلي:القاصر:من لم يستكمل أهلية الأداء، سواء أكان فاقدا لها كغير المميز أم ناقصها كالمميز([2]).

لكن نرى أن الزحيلي نفسه يستخدم مصطلح القاصر للصبي والمجنون معاً حيث يقول: للولي أو الوصي أو القيم أن يرهن مال القاصر (صبي أو مجنون ونحوهما) لدين للقاصر([3])

([1]) ابن منظور الأنصاري ا الإفريقى (٧١١هـ)لسان العرب/ دار صادر – بيروت/ الطبعة: الثالثة - ١٤١٤ هـ(٥/٩٥-٩٧).

([2])الدكتور وهبة الزحيلي/الفقه الإسلامي وأدلته/١٠/٧٣٢٧).

([3])وهبة الزحيلي/لفقه الإسلامي وأدلته/ ٦/ ٤٢١٤).

ويمكن القول أنّ مصطلح القاصر يقع على الصبي بصورة أولية ولايقع على غيره إلّا تبعا ولذلك سيعطي الباحث الأولوية ويسهب في بحثه أكثر من المجنون والنائم إن شا الله .

المطلب الثاني:تعريف الحكم التكليفي:

فالخطاب التكليفي:هو خطاب الله المتعلّق بفعل المكلّف بالاقتضاء ،أو التخيير.وبعض الأصوليين وبعض الأصوليين يعرّفون الخطاب التكليفي بالأحكام الخمسة المشهورة([٤]).

قال في البحر المحيط"الخطاب إن اقتضى الفعل اقتضاء جازما فإيجاب، أو غير جازم فندب. وإن اقتضى الترك جازما فتحريم أو غير جازم فكراهة، وإن اقتضى التخيير فإباحة، فالأحكام إذن خمسة هذا هو المشهور، وقوله:فالأحكام يعني:الأحكام التكليفية.

المطلب الثالث:تعريف الأحكام الوضعية:

وتعريف الحكم الوضعي قال الحافظ العلائي:"الخطاب الإنشائي المتعلّق بأفعال المكلّفين،لا بالاقتضاء والتخيير([٥]).

وقال بعض الأوصوليين:خطاب الله تعالى المتعلّق بجعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً له،أو مانعا منه ويسمى ب"بخطاب الإخبار"([٦]).

---

[٤])الزركشي/البحر المحيط/تحقيق/جماعة من علماء الأزهر/دار الزركشي/ص/٢٣١.

([٥])المجموع المذهب في قواعد المذهب/للحافظ العلائي/ تحقيق/مجيد علي العبيدي وأحمد خضير عباس/ دار عمار(١/ص٧٦).

([٦])الدكتور عبد الكريم النملة/الشامل في أصول الفقه(١/ص١٩٢).

أقسام الخطاب الوضعي:ينقسم الخطاب الوضعي إلى عدة أقسام كالخطاب التكليفي،وهذه الأقسام هي:

العلة أو السبب، الشرط ،المانع ،الصحة الفساد العزيمة والرخصة،وعند بعض المحققين من الفقهاء والأصوليين لا يعدّون الصحّة والفساد،من أحكام الشرعيّ،بل هما أوصاف للحكم الشرعيّ.

المطلب الرابع:الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي.

١-أنّ الحكم التكليفي يتعلّق بفعل المكلّف، والوضعيّ يتعلّق بفعل المكلّف،وغير المكلّف كالدابة، والمجنون،والصبي.

٢-أنّ الحكم التكليف لا يتعلق إلّا بالكسب،بخلاف الوضعيّ فإنه يتعلق العبد بغير ما كسب فإنّ الديّة تجب على العاقلة وإن يكن القتل مكتسبا لهم.

٣-أن الحكم التكليفي هو الأصل،والوضعي فرع عنه.

٤-أن حكم التكليفي لابدّ فيه من علم المكلّف،بخلاف الوضعي فإنّ منه ما يشترط علم المكلّف كعقد البيع وتعاطي الزنى ومنه ما لا يشترط فإن الضمان يجب بإتلاف الدابة والمجنون،والنائم،والصبيّ([٧]).

فإذاً رأينا التكليف والوضع قد يجتمعان في مسألة واحدة وقد يفترقان وهو نزر يسير من مسائل الفقه. فمثال اجتماعهما: كالإيمان والكفر،فالإيمان واجب والواجب من أقسام حكم التكليفي، كما أنّ الإيمان سبب لعصمة الدّم والمال،والسببية من أقسام الحكم الوضعي. وكذا الكفر حرام،وهو أيضا سبب لاستباحة الدم والمال([٨]).

([٧]) صلاح الدين العلائي/ المجموع المذهب في قواعد المذهب ا (٢٦/١).

([٨]) المصدر السابق ٢٦/١

المطلب الخامس:أقسام الأحكام الفقهية باعتبار التكليف والوضع.

حصر الإمام صلاح الدين العلائي في قواعده أبواب الفقه كلها باعتبارالخطاب الوضعي والتكليفي في أربعة أنواع:وهذه الأربعة هي كالآتي:

أحدها:ما اجتمع فيه خطاب التكليف،وخطاب الوضع جميعا من وجه واحد كالطهارة عن الحدث،والخبث،وأسباب الحدث الأكبر والأصغر،والصلّوات الخمسة المفروضة لأنّها سبب لعصمة الدم.

ثانيها:ما كان خطاب وضع فقط ولا تكليف،مثل أسباب الحدث غير المكتسب كالحيض والاحتلام،وجميع أوقات الصلوات ،ورؤية الهلال في الصوم والفطر،وكل سببٍ لا يقدر المكلّف تحصيله وإيجاده من هذا القسم .

ثالثها:ماكان خطاب تكليف،وليس سبباً لشيء آخر،ولا شرطاً فيه،ولا مانعاً،والتطوعات كلها من هذا القسم إذ ليست سبباً ولا شروطاً، ولا موانع.

رابعها:ما كان خطاب التكليف أولاً ثمّ صار من خطاب الوضع بعد الوقوع،كالبيع وأقسامه لأنه في أوله مباح والمباح من أقسام الخطاب التكليفي فإذا وقع وتمّ صار سبباً للملك([٩]).

([٩])العلائي/المجموع المذهب في قواعد المذهب/٢٧/١.

المبحث الثاني:تصرّفات القاصر وأحكامها في الفقه الإسلامي. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول:تصرّفات الصبي المميز.

المطلب الثاني:تصرفات المجنون.

المطلب الثالث:تصرّفات النائم وأحكامها في الفقه الإسلامي

المطلب الأول:تصرّفات الصبي المميز.

تنبيه: يرى الكاتب أنّ مصطلح القاصر يقع على الصبي بصورة أولية ولذلك يعطي الأولوية ويسهب في بحثه أكثر من المجنون والنائم .

التصرفات التي يباشرها الصبي المميز،على ضربين:

الأول: إما أن تكون في حقوق الله تعالى،وهي على ثلاثة أنواع:عبادات وعقائد، أو حقوقا مالية، أو عقوبات.

والثاني:إما أن تكون تلك التصرفات في حقوق العباد، وهي إما: مالية أو غير مالية.([١٠])

ونفرّع تفريعات لهذا القسمين من الحقوق فنقول حقوق الله: إما عبادات وعقائد،وإما مالية ،وإما عقوبات.

أ–تصرفات الصبي فيما يتعلّق بحقوق الله.

أولاً– حقوق الله التعبدية التعبدية فأمالعبادات البدنية كالصلاة، فلا خلاف بين أهل العلم في عدم وجوبها عليه إلا أنه يؤمر بأدائها في سن السابعة، ويضرب على تركها في سن العاشرة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلّم،" مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع([١١]).

([١٠])الموسوعة الفقهية الكويتية/

([١١]) مسند الإمام أحمد بن حنبل/ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت٢٤١) تحقيق/ شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون/

ثانيا–التصرّفات الاعتقاديةوأما والعقائد كالإسلام والإيمان:فاختلف العلماء في صحتها عن الصبي إلى قولين:

القول الأول:لا يصحّ إسلام الصبي حتى يبلغ إما بالسنّ أو بأمارة الاحتلام وهو مذهب الإمام الشافعي وعامّة أصحابه وزفر ابن هذي من أصحاب أبي حنيفة.

قال الإمام في(النهاية) والمنصوص عليه لصاحب المذهب قديما وجديدا أنه لا اعتبار بلفظ الصبي بالإسلام، ووجوده وعدمه بمثابة([١٢]). ومع هذا المنصوص الذي حكام إمام الحرمين عن الشافعي رحم الله الجميع إ لّا أنّي رأيت نقلاً لإمام العمراني صاحب البيان يحكي خلافا لأصحابنا حيث قال رحمه الله: فهل يحكم بإسلامه؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها الشيخ أبو حامد.([١٣])

أحدها:يصح إسلامه كقول الجمهور ويحكى هذا الطريق عن أبي سعيد الإصطخري،من أصحاب الوجوه.

ثانيها: لا يصح إسلامه؛وهو قول جمهور أصحابنا ،المنصوص لصاحب المذهب.

ثالثها: أن إسلامه موقوف. فإن بلغ ثم وصف الإسلام.. حكمنا بصحة إسلامه وهذا محكي عن ابن أبي هريرة من أصحاب الوجوه([١٤])

([١٢]) إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني(ت ٤٧٨) نهاية المطلب في دراية المذهب/ حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب/ الناشر: دار المنهاج/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧(٥٢٠/٨).

([١٣])الإمام العمراني أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (: /البيان في مذهب الإمام الشافعي/ تحقيق/قاسم محمد النوري/ الناشر: دار المنهاج – جدة/ الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م(جـ١٢/١٧١).

([١٤]) العمراني /البيان/١٢ ١٧١)/عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني (٦٢٣هـ) العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير/ محقق: علي محمد عوض – عادل أحمد عبد الموجود/ الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان/ الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ – ١٩٩٧م(٣٩٥/٦).

أدلة هذا القول:

واستدلّ القائلون بعدم صحّة إسلام الصبي أدلةً أهمها ما يلي:

الدليل الأول:قوله صلى الله عليه وسلّم:" رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ

الدليل الثاني:قياس الصبي على المجنون فقالوا: ولانه أحد من رفع القلم عنه فلم يصح إسلامه كالمجنون والنائم،

الدليل الثالث:ولأنّ التكلّم بكلمة الإسلام قول: تثبت به الاحكام فلم يصح من الصبى كالهبه([١٥])

المذهب الثاني: يصح إسلام الصبى إذا كان له عشر سنين وعقل الاسلام وهو مذهب أبي حنيفة وصاحباه وأحمد بن حنبل وسائر أصحابه، وإسحاق وابن أبى شيبة وأبو أيوب([١٦]) وهو مذهب الإمام أبو سعيد الاصطخري فيما حكاه عنه الرافعي في الشرح الكبير ومذهب البيهقي كما نقل الحافظ في التلخيص.

قال الدميري في (النجم) وهو —صحة إسلام الصبي– مذهب الأئمة الثلاثة، وبه قال الإصطخري وابن أبي هريرة، وحكم به الشيخ زين الدين ابن الكتناني أيام نيابته القضاء، وكذلك قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة، واختاره الشيخ –السبكيأولا ثم رجع عنه([١٧]).

([١٥]) الإمام النووي/المجموع شرح المهذب/٢٢٣/١٩.

([١٦]) موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي ابن قدامة المقدسي(ت ٦٢٠هـ)، الناشر: مكتبة القاهرة/ الطبعة: بدون طبعة/ تاريخ النشر: ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م(١٤/٩).

([١٧]) كمال الدين لدَّمِيري أبو البقاء الشافعي (٨٠٨هـ) النجم الوهاج/دار المنهاج (جدة)/ المحقق: لجنة علمية/الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م(٧٤/٦).

سبب الخلاف بين الحنفية والشافعية

ذكر شهاب الدين الزنجاني رحمه الله في (تخريخ الفروع على الأصول) أن مذهب جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية أن العقل ليس له دخل في الأمر والنهي-تشريع الأحكام-إلى أن قال:" وذهب المنتمون إلى أبي حنيفة رض الله عنه من علماء الأصول إلى أن الأفعال تقسم إلى ثلاثة أقسام:

-فمنها ما يستقل العقل بدرك حسنه وقبحه بديهة كحسن الصدق الذي لا ضرر فيه -وقبح الكذب الذي لا نفع فيه

-ومعنى استقلال العقل بدرك ذلك عندهم أنه لا يتوقف على إخبار مخبر

-ومنها ما يدرك حسنه وقبحه بنظر العقل كحسن الصدق المشتمل على الضرر وقبح الكذب المشتمل على النفع

-ومنها ما لا يستقل العقل بدرك حسنه وقبحه أصلا دون تنبيه الشرع عليه كحسن الصلاة والصوم والحج والزكاة وقبح تناول الخمر والخنزير ولحوم الحمر الأهلية

ثم قال: يتفرع عن هذا الأصل مسائل

منها إن إسلام الصبي المميز لا يصح عندنا([١٨]). وبهذا النقل فهمنا أنّ الحنفية يقولون:أنّ الإسلام والكفر ممّا يدرك في العقل حسنا وقبحا فلا يتوقف على النّص من الشارع.

([١٨]) شهاب الدين الزَّنْجاني (٦٥٦هـ) تخريج الفروع على الأصول/المحقق: د. محمد أديب صالح/مؤسسة الرسالة – بيروت/الطبعة: الثانية، ١٣٩٨(٢٤٦)

أماسبب الخلاف بين الشافعية والحنابلة فهي تدور على صحّة الأحاديث ودلالتها على المسألة وخاصة قصة إسلام سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه.

أما المالكية فلم يقف الباحث نقلاً من مصادرهم إلاّ ما ينقل عنهم بعض الأئمة من المذاهب الأخرى كالعمراني في البيان،وابن قدامة في المغني،وابن القيم في أحكام أهل الذمّة.لكن رأيت كلاما للقرافي في الذخيرة في باب الردة يقول: إن ارتد ولد المسلم المولود على الفطرة وعقل الإسلام ولم يحتلم قال ابن القاسم يجبر على الإسلام بالضرب والعذاب فإن احتلم على ذلك ولم يرجع قتل([١٩])

أدلة هذا القول:استدلّ القائلون بصحّة إسلام الصبي أدلة كثيرة أهمها مايلي:

الدليل الأول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه حتى يعرب عنه لسانه إما شاكرا واما كفورا

الدليل الثاني:قوله عليه الصلّاة والسلّام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، والصبي من الناس.

الدليل الثالث:قصة إسلام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وقبول النبي صلى الله عليه إسلامه منه

نقاش البيهقي في قصّة إسلام علي رضي الله سنداً ودلالة.

ناقش الإمام البيهقي في (السنن الكبرى) في باب من قال: يحكم بصحة إسلام الصبي.–فقال:"واختلف أهل العلم في سنه يوم أسلم.ونقاشه في المسألة كالآتي:

١–ففي أكثر الروايات كان رضي الله عنه بلغ من السن حين صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قدرا يحتمل أن يكون احتلم فيه،

([١٩]) أبو العباس شهاب الدين القرافي/ الذخيرة/ محمد حجي وسعيد أعراب/١٦/١٢

٢- وما روي من الشعر محتمل للتأويل مع ضعف إسناده،

٣-على أن الحكم بصحة قول البالغ دون الصبي المميز وقع شرعة(حكما) بعد إسلام علي رضي الله عنه، فإسلامه كان محكوما بصحته،للأسباب التالية:

الأول: إما لأنه بقي حتى وصف الإسلام بعد بلوغه،

الثاني: أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بالدعاء إلى الإسلام، وغيره من الصبيان غير مخاطب،

والثالث:أو لأن قول الصبي المميز إذ ذاك كان محكوما بصحته قبل ورود الشرع بغيره،

الرابع:أو كان قد احتلم فصار بالغا به، والله أعلم

الدليل الرابع: لعموم قوله صلى الله عليه وسلّم:" من قال لا إله إلا الله دخل الجنة"

الدليل الخامس: ولأن الإسلام عبادة محضة، فصحت من الصبي العاقل، كالصلاة والحج.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله:" إذا تأملنا الشرع رأينا اعتباره لأقواله أكثر من إهداره لها، وإنما تهدر فيما فيه عليه ضرر، كالإقرار بالحدود، والحقوق، فأما ما هو نفع محض له في الدنيا، والآخرة كالإسلام، فاعتبار قوله فيه أولى من إهداره، إذ أن أصول الشرع تشهد باعتبار قوله فيه([٢٠]).

الدليل السادس:ولأن الله تعالى دعا عباده إلى دار السلام، وجعل طريقها الإسلام، وجعل من لم يجب دعوته في الجحيم والعذاب الأليم، فلا يجوز منع الصبي من إجابة دعوة الله، مع إجابته إليها.

([٢٠]شمس الدين ابن قيم الجوزية (٧٥١هـ)/ أحكام أهل الذمة/تحقيق/ وسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري/ الطبعة: الأولى، ١٤١٨ – ١٩٩٧(٢/٩٠١).

الدليل السابع:أن الكفر والإسلام من خطاب الوضع فلا يفتقران ألى العلم والفهم قال القرافي في الذخيرة:" والكفر والإيمان فعلان للقلب فاعتبرا قاعدة خطاب التكليف يفتقر إلى العلم والقدرة وأهلية التكليف وخطاب الوضع لا يفتقر لشيء من ذلك في أكثر صوره وهو وضع الأسباب والشروط والموانع كالتطليق بالإعسار والتوريث بالأسباب والضمان بالإتلاف والزكاة بملك النصاب وغير ذلك ومقتضى هذه القاعدة اعتبار الإسلام والكفر من الصبيان لأنهما سببان للعصمة([٢١]).

الدليل الثامن :قال الحافظ رحمه الله في "التلخيص" واحتج البيهقي على صحة إسلام الصبي بحديث أنس كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه أنه مرض فعرض عليه الإسلام فأسلم([٢٢]).

الدليل التاسع: وبحديث ابن عمر أنه عرض الإسلام على ابن صياد وهو لم يبلغ الحلم متفق عليه فهذان الحديثان احتجهما البيهقي على صحة إسلام الصبي كما نقله الحافظ في التلخيص لكنّي لم أقف في مصنّفات البيهقي في السنن والمعرفة

والراجح والله أعلم هو قول الجمهور(أبي حنيفة ومالك وأحمد وأبي سعيد الإصطخري من كبار أصحابنا) القائلين بصحة إسلام صبي المميز هذ وقد أطال ابن القيم الاستدلال في كتابه (أحكام الذمة) والرد على أصحاب الشافعي فيها والله أعلم.

([٢١])القرافي/ الذخيرة/ ج ١٢/ ص ١٥-١٦ .

([٢٢]) الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن أحمد أبو الفضل بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢)/ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير/ الناشر: دار الكتب العلمية/ الطبعة الأولى ١٤١٩هـ. ١٩٨٩م.(١٧٨/٣

فأماردة الصبي فقد إختلف العلماء أيضا على قولين:

القول الأول:عدم صحة ردة الصبي فقد ذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية إلى عدم صحة ردة الصبي لأنها ضرر محض.

القول الثاني:صحة ردة الصبي وذهب أبو حنيفة ومحمد والمالكية إلى الحكم بصحة ردته، وتجري عليه أحكام المرتدين ما عدا القتل([٢٣]).

والخلاف في هذه المسألة فرع عن صحة إسلام الصبي قال المطيعي في(تتمة المجموع):" تصح الردة من كل بالغ عاقل مختار، فأما الصبى والمجنون فلا تصح ردتهما لقوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق)..... ثم ذكر الخلاف بين الشافعية والحنفية وأدلة الشافعية في عدم صحة ردة الصبي إلى أن قال:" ومرد هذا الخلاف إلى صحة إسلام الصبي([٢٤])

فيمكن تلخيص مذاهب العلماء في صحة إسلام الصبي وردته كالآتي:

١-لا يصح من الصبي إسلام ولاردة قول مطرد- الشافعية

٢-الحنفية يصحّ إسلامه وردته مطرد-الحنفية

٣-يصحّ إسلامه ولا تصحّ منه ردته.مفصّل- الحنابلة

---

(٢٣)الموسوعة الفقهية الكويتية(١٥٨/٧).

([٢٤]) محيي الدين يحي بن شرف أبو زكريا النووي (ت ٦٧٦) المجوع شرح المهذب/: دار الفكر(٢٢٣/٢٠).

ثالثا– حقوق الله المالية المتعلّقة على مال الصبيوأما حقوق الله سبحانه وتعالى المالية كالزكاة، فإنها تجب في ماله عند المالكية والشافعية والحنابلة، ولا تجب في ماله عند الحنفية.

رابعا– وأما العقوبات المتعلقة بحقوق الله سبحانه وتعالى كحد السرقة وغيره، فإنها لا تقام على الصبي، وهذا محل اتفاق عند الفقهاء([٢٥]).

تنبيه

قال الكاتب عف الله عنه:" وهذ الاتفاق نقله أصحاب الموسوعة الكويتية وفيه نظر فإنّ ابن حزم رحمه الله حكى الخلاف في (مراتب الإجماع) حيث قال:" اختلفوا في الصبي الذي يعقل ما يفعل وان لم يبلغ أيقام عليه حد السرقة ويقتل في الردة أم لا ولا أقطع على إجماع في اسقاط سائر الحدود عنه([٢٦])

لكن في مذهب إمام الشافعي ليس على الصبي حد في أي حدٍ كان وهو الذي تقتضي أصول المذهب وفي (نهاية المحتاج) " فلو كان أحدهما(السارقان) صبيا أو مجنونا لا يميز فيقطع المكلف،([٢٧]).

([٢٥])الموسوعة الفقهية الكويتية/٧/١٥٩.

([٢٦])أبو محمد ابن حزم الظاهري الأندلسي/مراتب الإجماع/الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت

([٢٧]) شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي(ت١٠٠٤) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج/ الناشر: دار الفكر، بيروت/ الطبعة: ط أخيرة – ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م(٧/٤٤٢).

ب- تصرّفات الصبي فيما يتعلّق بحقوق العباد.تنقسم إلى قسمين:

الأول:حقوق مالية.

والثاني:حقوق جنائية:

فأما الحقوق المالية المتعلقة بالصبي كضمان المتلفات وأجرة الأجير ونفقة الزوجة والأقارب ونحو ذلك فإنها تجب في ماله؛ لأن المقصود منها هو المال، وأداؤه يحتمل النيابة، فيصح للصبي المميز أداؤه، فإن لم يؤده أداه وليه([٢٨])

وأما جناية الصبي

فلم أقف على أحد من فقهاء الإسلام قال بإقامة حد القصاص على الصبي مميزاً كان أم لا، والمشهور من فقهائنا الشافعية سقوط القود على الصبي

أما الدية المترتبة على جناية الصبي هل تعتبر خطأ على الإطلاق بدون تفريق بين قتله عمداً وبين قتله خطأً.أم لا فقد نص الشافعي فيما نقله المزني في (مختصره) على قولين في المسألة:"حيث قال:" **وقيل:** جناية الصبي والمعتوه عمدا وخطأ يحملها العاقلة، **وقيل:** لا؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قضى أن تحمل العاقلة الخطأ في ثلاث سنين فلو قضينا بها إلى ثلاث سنين خالفنا دية العمد لأنها حالة فلم يقض على العاقلة بدية عمد بحال." ([٢٩]).

([٢٨]) الموسوعة الفقهية الكويتية/٧/ص١٥٩.

([٢٩]) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني (ت: ٢٦٤هـ)/ مختصر المزني/ دار المعرفة – بيروت/ **سنة النشر**: ١٤١٠هـ/١٩٩٠م(٣٥٣/٨).

(قال المزني) هذا هو المشهور من قوله.وهذا هو ترجيح المزني رحمه الله للقول الأخير الذي يعتبر قتل الصبي عمدا إذا كان قتله عمدا([٣٠]) ولهذا قال الزركشي في البحر المحيط:" الخلاف في أن عمد الصبي عمد أو خطأ، والأصح " أنه عمد " ([٣١])

أدلة هذا القول: واستدلّ الشافعيون على هذا القول بأدلة منها:

١- لأن صفة العمد متميزة فكان حكمها متميزا.

٢-قياساً على تفريق عمده ونسيانه في العبادات لأن الصبي قد وقع الفرق فيه بين عمده ونسيانه إذا تكلم في الصلاة وأكل في الصيام وتطيب في الحج, فوجب أن يقع الفرق بين عمده وخطئه في القتل

٣- لأن كل من وقع الفرق بين عمده وخطئه في العبادات وقع الفرق بينهما في الجنايات كالبالغ العاقل.([٣٢]).

على الغير فقد اختلف العلماء في هل تعتبر جنايته على الغير عمداً أو خطأ؟ على قولين:

القول الثاني: ذهبت الحنفية والمالكية والحنابلة؛إلى أنّ جناية الصبي والمجنون تعتبر خطأ على الإطلاق بدون تفريق بين قتله عمداً وبين قتله خطأً.

أدلة هذا القول:استدلّ القائلون هذا القول بأدلة كثيرة منها:

١- لأن فعل الصبي لا يوصف بالتقصير، فلا يصلح سببا للعقوبة لقصور معنى الجناية في فعله، ولكن تجب في فعله الدية؛

([٣٠]) مختصر المزني/٨/٣٥٣).

([٣١]) أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت: ٧٩٤هـ)المنثور في القواعد/ الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية/ لطبعة: الثانية، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م(٢/٣٠٠١

([٣٢]) الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت ٥٠٢ .)/ بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي/المحقق: طارق فتحي السيد/دار الكتب العلمية/الطبعة: الأولى، ٢٠٠٩ م(١٢/٢٩١).

٢-لأنها وجبت لعصمة المحل، والصبا لا ينفي عصمة المحل؛

٣-ولأن المقصود من وجوبها المال، وأداؤه قابل للنيابة([٣٣])

جـ-تصرّفات الصبي كالبيع والشراء وغيرهما

أما تصرفات الصبي المالية، ففيها تفصيل على النحو الآتي

١-تصرفات نافعة له نفعا محضا، وهي التي يترتب عليها دخول شيء في ملكه من غير مقابل، مثل قبول الهبة والصدقة والوصية والوقف، وهذه تصح منه، دون توقف على إجازة الولي أو الوصي؛ لأنها خير على كل حال.

٢- صرفات ضارة بالصغير ضررا محضا، وهي التي يترتب عليها خروج شيء من ملكه من غير مقابل، كالهبة والصدقة والوقف وسائر التبرعات والطلاق والكفالة بالدين، وهذه لا تصح منه، بل تقع باطلة، ولا تنعقد، حتى ولو أجازها الولي أو الوصي؛ لأنهما لا يملكان مباشرتها في حق الصغير فلا يملكان إجازتها.

٣- تصرفات دائرة بين النفع والضرر بحسب أصل وضعها، كالبيع والإجارة وسائر المعاوضات المالية، وهذه يختلف الفقهاء فيها:

-فعند الأحناف هذه المعاملات موقوفة بإجازة الولي أو الوصي.

- وعند المالكية تقع صحيحة لكنها لا تكون لازمة، ويتوقف لزومها على إجازة الولي أو الوصي.

([٣٣]) الموسوعة الفقهية الكويتية/٧/ص١٥٩.

– وعند الشافعية والحنابلة لا يصح صدورها من الصبي، فإذا وقعت كانت باطلة لا يترتب عليها أي أثر. وقد توسع صاحب التقرير من الحنفية في تناول أنواع تصرفات الصبي فليبحث هناك([٣٤])

المطلب الثاني:تصرفات المجنون.

والجنون يؤثر في أهلية الأداء، فهو مسقط للعبادات كالصلاة والصوم والحج،وفي وجوب الزكاة على مال المجنون خلاف بين الفقهاء

قال عبد العزيز البخاري:" القياس في الجنون أن يكون مسقطا للعبادات كلها أي مانعا لوجوبها أصليا كان أو عارضا قليلا كان أو كثيرا....لأنّ الجنون يزيل العقل فلا يتصور فهم الخطاب والعلم به بدون العقل([٣٥])

والأحكام التي تثبت للمجنون تختلف باختلاف متعلقها على النحو التالي:

أ– أحكام أقواله.

ب– أحكام أفعاله.

ج– أحكام تركه.

أما أقواله فهي لغو لا يؤاخذ عليها ولا يترتب عليها حكم شرعي لا في الدنيا و لا في الآخرة، فلو قذف أو باع أو اشترى فلا أثر لشيء من ذلك.

أما أفعاله،فتفصيل القول فيها كالآتي:

١– فإذا كانت عبادات، فهي لغو لا أثر لها

([٣٤]) الموسوعة الفقهية الكويتية/١٥٩/٧)ابن أمير حاج أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج/ التقرير والتحبير/ **دار** الكتب العلمية/ الطبعة: الثانية، ١٤٠٣هـ –

([٣٥])عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي (٧٣٠)/كشف الأسرار شرح أصول البزدوي/الناشر: دار الكتاب الإسلامي/٤/٢٦٤).

٢–وإن كان فيها ضرر بالغير فهو لا يؤاخذ عليها في الآخرة، وأما في الدنيا فعليه ضمانها إن ترتب عليها ضمان، فلو أتلف مالا أو قتل قتيلا فلا إثم عليه ولا قصاص ولكن الضمان يثبت في ماله أو على عاقلته؛ لأن الضمان ليس مشروطا بالتكليف.

وأما الترك فإنه لا يؤاخذ عليه فيما يتعلق بحقوق الله، فلا يطلب منه القضاء لو أفاق من جنونه إلا إذا كانت العبادة لم يذهب وقتها،كما هو مذهب الجمهور([٣٦])

قال النووي في امنهاج :فبالجنون تنسلب الولايات واعتبار الأقوال([٣٧]).

أما أهلية الوجوب، فلا يؤثر فيها الجنون، فإن المجنون يرث ويملك لبقاء ذمته، والمتلفات بسبب أفعاله مضمونة في ماله كالصبي الذي لم يصل إلى سن التمييز.

وتترّتب الآثار على أفعال المجنون إذا جنى أو تعدّى على الغير بخلاف الأقوال لأنّ من الأفعال" ما يعتبر كإحباله وإتلافه مال غيره وتقرير المهر بوطئه وترتب الحكم على إرضاعه والتقاطه واحتطابه واصطياده" ([٣٨])

([٣٦]) عياض بن نامي بن عوض السلمي/أصول الفقه الذي لا يسع جهله/دار التدمرية، الرياض/الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥(ص٨٠).

([٣٧]) محي الدين النووي/منهاج الطالبين/ الناشر دار المنهاج/ص ٢٥٦.

([٣٨]) شمس الدين الرملي (ت١٠٠٤هـ/نهاية المحتاج/٤/٣٥٥.

المطلب الثالث:أفعال النائم وتصرّفاته في الفقه الإسلامي.

النوم عارض طبعي يطرأ على الإنسان بالضرورة فيعطل العقل عن الإدراك، ويعجز عن الفهم في حال النوم.

وللنائم حالتين:

حالة في النوم:

وبعد النوم:

أما تصرّفاته في حالة النوم فهي نوعان: أقوال وأفعال .

١–أما تصرّفاته القولية في حالة النوم فجميع عبارات النائم في التصرفات القولية لغو، فلا ينعقد إحرامه بحج أو عمرة أو صلاة، ولا نطقه بنية الصوم، ولا يصح نذره ولا تنعقد يمينه، ولا يقع طلاقه، ولا يقبل إقراره بحق لله أو لآدمي، ولا يصح إيجابه بعقد ولا قبوله،ولهذا قال الأرموي في (نهاية الوصول):" وعلى هذا لا يجوز تكليف النائم في حالة النوم، لذهوله عن المأمور به، وعن شرائطه، ولعدم قصد الامتثال منه، بل هو بعدم جواز التكليف أولى من الصبي والمجنون، لفقده أصل الفهم دونهما. ، ([٣٩]) ووجه عدم تكليف النائم :أنّ النائم غير مكلّف في حالة النوم ، لأن التكليف استدعاء حصول الفعل على قصد الامتثال، وهو محال عادة وشرعا ممن لا شعور له بالأمر كالنائم ونحوه، فلا يناسب توجيه الخطاب إليه.

([٣٩]) صفي الدين الأرموي الهندي (٧١٥ هـ)/ نهاية الوصول في دراية الأصول / المحقق: د. صالح بن سليمان اليوسف – د. سعد بن سالم السويح/ الناشر: المكتبة التجارية بمكة المكرمة/٣/١١٢٤.

ومع هذا يجب على النائم ما فات من الصلوات أثناء نومه ووجوب قضاء ما فاته من الصلاة والصيام في حالة النوم لا يدل على أنه مخاطب بهما في حالة النوم، لأنّ القضاء يعتمد على وجود سبب الوجوب لا على الوجوب نفسه.([٤٠]).

وقد استشكل الطوفي رحمه الله تكليف النائم بالضمان والجنائيات مع أنه غير مخاطب فقال:" لو لم يكن هؤلاء مكلفين، لما ثبتت أحكامهم، كالغرامات عن الجنايات، كالنائم ينقلب على مال فيتلفه، أو إنسان فيقتله، ونفوذ الطلاق، ونحوه من الأحكام الثابتة في حقهم.

وجوابه: أن ذلك ليس من باب التكليف، بل من باب ربط الحكم بالسبب..... لأن أسباب الأحكام المتكررة هي قائمة مقام الخطاب بمسبباتها([٤١]).

٢–أما تصرّفات النائم الفعلية فهي إما جناية على الأشخاص، وإما جناية على الأموال بالتلف.

فأما جناية النائم في حالة النوم:فقد اعتبر الفقهاء جناية النائم على نفس و عضو خطأ أو جاريا مجرى الخطأ، فتجرى في فعله في كلا التعبيرين أحكام الخطأ، فإذا انقلب نائم على إنسان بجنبه فقتله فهو خطأ أو كالخطأ في الحكم([٤٢])

وأما الجناية على الأموال فقد اتفق الفقهاء على وجوب ضمان إتلاف النائم "النائم في إتلاف مال الغير كالمستيقظ تماما فيضمن. فإن ضمان المال لا يشترط فيه

([٤٠]) صفي الدين الأرموي الهندي/ نهاية الوصول في دراية الأصول/٣/١١٢٤.

([٤١]) سليمان بن عبد القوي نجم الدين الطوفي/ شرح مختصر الروضة/المحقق : عبد الله بن عبد المحسن التركي/مؤسسة الرسالة/ الأولى ، ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧/١/ص١٨٩.

([٤٢])الموسوعة الفقهية الكويتية/٤٢/٢٤.

التكليف، بل يشترط أن يكون الجاني من أهل الوجوب، فالمكلف وغير المكلف فيها سواء([٤٣]).

([٤٣]) نفس المصدر ٢٥/٤٢.